InDret

# *Comentaris pràctics a la Llei d'Enjudiciament Civil*

*Arts. 1 a 5*

**Víctor Moreno Catena**
**Facultat de Dret**
**Universidad Carlos III de Madrid**

**Luis Martín Contreras**
**Facultat de Dret**
**Universidad Carlos III de Madrid**

**Working Paper núm.: 206**
**Barcelona, abril de 2004**
**www.indret.com**

## Article 1. *Principi de legalitat processal*[1].

**En els processos civils, els tribunals i els qui hi acudeixin i intervinguin han d'actuar d'acord amb el que disposa aquesta Llei.**

L'art. 1 de la LEC consolida el principi de legalitat processal, exigint que tothom compleixi les seves disposicions en el desenvolupament de les actuacions processals civils.

Que la primera disposició de la llei processal sigui precisament proclamar el seu valor i ordenar el sotmetiment de tothom a les seves disposicions no deixa de resultar important a hores d'ara, encara que aquesta hagi estat una norma tradicional, atès que l'art. 1 de la vella LEC de 1881 ja disposava que "el que haya de comparecer en juicio, tanto en asuntos de la jurisdicción contenciosa como de la voluntaria, deberá verificarlo ante el juez o tribunal que sea competente, y en la forma ordenada por esta Ley".

En efecte, és important plantejar la vigència del principi de legalitat perquè en ocasions els jutges esquiven els preceptes de les lleis processals i perquè el legislador aprova lleis processals incompletes, això és, deixant llacunes que només poden reblar-se amb enginy i inventiva.

Aquest precepte manté intacte el principi de legalitat, que és essencial per a la feina dels tribunals i que legitima llur actuació en la mesura que només estan sotmesos a la llei, però que sens dubte també en són tributaris.

Per això és convenient parar esment a les infraccions de la llei processal i procedir a denunciar-les per les vies que la LEC proporciona. El rebuig de les denúncies d'infraccions processals per a quan no s'hagués arribat a produir una efectiva indefensió sol aparèixer com a fonamentació habitual en resolucions judicials, invocant aleshores la salvaguarda d'altres valors o principis constitucionals; però el ben cert és que la llei processal s'ha vulnerat ja sense remei. No obstant això, comptant que la defensa d'aquests valors o principis és de summa importància, no es pot realitzar deixant de banda la llei, perquè en aquest cas soscavaríem al seu torn els pilars essencials de l'Estat democràtic de dret.

Les disposicions processals no són normes de segon ordre, contraposades a les normes materials, que es presenten com aquelles rellevants per a la tutela dels drets subjectius, ni tampoc no es tracta de disposicions que entrebanquin la feina dels tribunals, sinó que representen una garantia bàsica per a l'exercici de la funció jurisdiccional.

És veritat que entre aquestes normes processals hom en pot trobar algunes que institueixen garanties essencials, fins i tot de rang constitucional, com la que ordena l'emplaçament regular

[1] BOE suplement núm. 2, de 5 de febrer del 2000, en llengua catalana. Correcció d'errades BOE núm. 90, de 14.4.2000, p. 15278 ss. i BOE núm. 180, de 28.7.2001, p. 27746

del demandat per a què pugui ser oït; però n'hi ha d'altres, a més, que fixen un tràmit de menor rellevància, com les d'aportació de còpies, i algunes que assenyalen terminis dels cridats impropis, ordenant una actuació del jutge. Aquesta distinció, que exigeix salvaguardar les garanties essencials del procediment, d'audiència i defensa, no autoritza a desconèixer el valor de la resta de preceptes processals, que en qualsevol cas institueixen una garantia.

La infracció de les primeres se sanciona amb la nul·litat de ple dret, com succeeix amb la falta de jurisdicció o de competència objectiva o funcional, les actuacions realitzades sota violència o intimidació, o sense la intervenció preceptiva d'advocat o prescindint de normes essencials del procediment quan s'hagi pogut produir indefensió (art. 225 LEC, sense vigència fins que no es reformin els arts. 238 i s. LOPJ).

Els defectes de forma en els actes processals que impliquin absència dels requisits indispensables per aconseguir el seu fi o determinin una efectiva indefensió s'han de fer valer per mitjà dels recursos establerts a la llei contra la resolució de què es tracti (art. 227.1, sense vigència fins que no es modifiqui la LOPJ). Es tracta d'una infracció que, pel fet d'afectar el dret fonamental de l'art. 24.1 CE, una vegada produïda o quan l'acte no pugui aconseguir finalment el seu propòsit, també comporta la sanció de la nul·litat.

Amb un criteri de protecció de les parts gravades per una resolució, es disposa que aquestes podran interposar els recursos previstos a la llei contra les resolucions judicials que els afectin desfavorablement (art. 448.1), de manera que la seva estimació ocasionarà l'anul·lació de la resolució contrària a la llei. El recurs de reposició es presenta com l'instrument adequat per a resoldre les infraccions processals, atès que s'hi ha d'expressar la contravenció en què la resolució hagués incorregut a judici del recurrent (art. 452, deixant de banda l'exigència de citar el concret precepte processal que es considerava infringit com preveia l'antic art. 377.I de la LEC de 1881); a més a més, el litigant ha d'haver denunciat la falta si hi hagués tingut oportunitat processal, i sol·licitat la subsanació si el defecte fora sanable, perquè en qualsevol altre cas no prosperarà el recurs d'apel·lació (art. 459) ni l'extraordinari per infracció processal (art. 469.2).

Juntament amb aquestes infraccions de normes processals, la LEC contempla altres contravencions a què no s'hi connecta cap conseqüència, com l'incompliment d'alguns terminis, ja que, segons l'art. 229, les actuacions judicials realitzades fora del temps establert només podran anul·lar-se si ho imposés la naturalesa del terme o termini.

El sotmetiment del jutge a la llei no només li impedeix així que pugui obviar les lleis processals i acudir tan sols i directament a la Constitució, sinó que al propi temps exigeix al legislador que proporcioni als tribunals uns instruments que resultin suficients i útils per a l'exercici de la potestat jurisdiccional, rebutjant clàusules obertes, que requereixen una integració per part del jutge, perquè d'aquesta manera el propi legislador estaria permetent i, fins i tot, incitant jutges i tribunals a la "creativitat judicial" extralegal.

**Article 2.** *Aplicació en el temps de les normes processals civils.*

**Llevat que s'estableixi una altra cosa en disposicions legals de dret transitori, els afers que corresponguin als tribunals civils els han de substanciar sempre aquests tribunals civils d'acord amb les normes processals vigents, que mai no han de ser retroactives.**

L'eficàcia general de les normes jurídiques depèn, en primer terme, d'una clara delimitació del seu àmbit temporal i espacial. En aquest sentit, els principis de legalitat i de seguretat jurídica exigeixen conèixer amb precisió quines normes regeixen en cada moment i quin és l'àmbit espacial en què han de ser aplicades. Aquesta exigència cobra especial importància en l'ordre processal, perquè aquí la vigència dels instruments del procediment i l'àmbit d'actuació dels tribunals no han d'oferir cap dubte.

La LEC dedica set disposicions transitòries a regular l'inexcusable règim que han de seguir les situacions processals subsistents a la seva entrada en vigor, i consagra un precepte amb vocació general i de naturalesa garantista, l'art. 2, a l'aplicació en el temps de les normes processals civils, en què es concreta el principi constitucional d'irretroactivitat, establert com a regla general i només susceptible d'excepció per les disposicions de Dret transitori.

La LEC manté en el seu art. 2 el principi general d'irretroactivitat en l'aplicació de les normes processals. Per tant, aquesta llei serà sempre aplicada als fets i a les situacions processals futures, entenent-se per tals els procediments iniciats a partir del 8 de gener de 2001, amb independència que les situacions o relacions jurídiques de dret material que puguin donar lloc al procés hagin nascut o haguessin estat constituïdes durant el període de vigència de la vella llei. Això resol el problema dels drets materials adquirits, la projecció processal dels quals és independent del moment en què aquests drets van néixer o van ser constituïts.

Les set Disposicions transitòries de la LEC contenen els respectius punts de referència que marquen el fi de les velles normes processals en els procediments en curs. Aquest règim únicament permet exhaurir, conforme a la LEC de 1881, la tramitació dels procediments que es trobin en fase de recurs de cassació (disp. trans. quarta), i dels judicis executius en què s'hagués iniciat el procediment de constrenyiment (disp. trans. cinquena). Un cop en vigor la LEC, les seves disposicions normatives s'apliquen automàticament al règim de recursos contra resolucions interlocutòries sigui quin sigui l'estat del procediment (disp. trans. primera), al procés d'execució encara que ja s'haguessin iniciat les actuacions executives, i a les mesures cautelars que poguessin interessar-se en el curs del procediment, podent-se sol·licitar la revisió d'aquelles ja adoptades conforme a la normativa derogada. A més a més, les normes derogades només podran estendre la seva vigència fins que conclogui la instància en tramitació, regint des d'aleshores la nova LEC per a la segona instància o la cassació (disp. trans. tercera). En qualsevol cas, sempre serà possible interessar l'execució provisional encara que la resolució hagi estat adoptada a la instància

corresponent conforme a les normes de l'antiga llei processal civil (disp. trans. segona, tercera i quarta).

## Article 3. *Àmbit territorial de les normes processals civils.*

**Amb les úniques excepcions que puguin preveure els tractats i convenis internacionals, els processos civils que se segueixin en el territori nacional es regeixen únicament per les normes processals espanyoles.**

L'art. 3 de la LEC consagra, com a principi general, la regla segons la qual el procés es regeix per la llei del lloc on aquest se segueix. Es tracta d'un principi clàssic, de naturalesa eminentment processal, que, no obstant això, no es recollia a l'antiga LEC, sinó a l'art. 8.2 CC, segons el qual «les lleis processals espanyoles seran les úniques aplicables a les actuacions que se substanciïn en territori espanyol, sens perjudici de les remissions que aquestes puguin fer a les lleis estrangeres, respecte dels actes processals que hagin de realitzar-se a Espanya». Amb encert sistemàtic, la nova LEC ha derogat l'art. 8.2 CC per a incloure-hi, dins la regulació processal civil, la norma que disciplina l'àmbit territorial d'aplicació de les normes processals civils.

Poden identificar-se tres raons fonamentals que justifiquen la utilitat del principi *lex fori regit processum* (CALVO CARAVACA). En primer terme, és una regla avalada per la lògica i la raó pràctica, en virtut de la qual els tribunals de cada país aplicaran, com a norma general i per a millor conèixer, les lleis processals nacionals per a la tramitació dels litigis. En segon lloc, afavoreix la seguretat jurídica, tant en l'acompliment correcte de la funció jurisdiccional, com en la previsió i el coneixement de les normes processals per les parts litigants. En tercer lloc, s'acomoda al principi de sobirania, una de les manifestacions del qual es concreta en la potestat jurisdiccional, i a les normes que disciplinen el seu exercici.

Tot i ser l'art. 3 sistemàticament oportú i manifestar una regla general correcta, s'adverteixen alguns defectes de fons, provocats per una redacció massa concisa i poc precisa. El principal problema que planteja és la falta d'un tractament bilateral que reconegui l'aplicació de la *lex fori* per a les actuacions processals a practicar a l'estranger, quan siguin interessades pels jutges espanyols. Si els jutges espanyols disposen de llibertat per aplicar normes processals nacionals o estrangeres en les actuacions interessades per un jutge estranger que hagin de practicar-se en el nostre país, s'hauria de permetre, en justa correspondència, que quan un jutge espanyol interessi la pràctica d'una diligència a l'estranger, aquesta diligència pugui ajustar-se a les normes processals del país on hagi de ser practicada, i no necessàriament a les normes espanyoles, com disposa l'art. 3 LEC. D'aquí que hagués resultat convenient permetre que certs actes d'assistència judicial internacional es duguessin a terme d'acord amb la llei estrangera de l'Estat del jutge col·laborador (CALVO CARAVACA).

El principi de la *lex fori* no és tanmateix absolut, per la qual cosa són possibles excepcions a aquesta regla, derivades tant del que disposen els Convenis Internacionals subscrits per Espanya —única possibilitat que contempla l'art. 3 LEC— com de normes generades a l'ordenament jurídic intern.

Les excepcions que exclouen l'aplicació preferent de la llei processal nacional a favor de normes processals estrangeres, en virtut de Conveni Internacional o de previsions contingudes en el dret intern espanyol no són poques, ni fàcils de sistematitzar.

## Article 4. *Caràcter supletori de la Llei d'Enjudiciament Civil.*

**En defecte de disposicions en les lleis que regulen els processos penals, contenciosos administratius, laborals i militars, els són aplicables, a tots ells, els preceptes d'aquesta Llei.**

La LEC apareix com la disposició bàsica del nostre ordenament jurídic processal, capaç d'integrar les llacunes normatives de les altres lleis que regulen l'activitat jurisdiccional en altres branques del Dret.

Ja a l'etapa de codificació en el nostre país a les darreries del segle XIX i a principis del XX, sorgeix la idea de la supletorietat com a remei lògic per a les llacunes apreciades en els textos legals. Aquest criteri de supremacia no arribà tanmateix a ser plasmat en cap norma. La nova LEC introdueix per primera vegada aquest caràcter en el seu art. 4 que sembla remetre a la idea d'un codi processal únic, que pogués servir per a tots els ordres jurisdiccionals, que s'encarregaria de regular matèries com els pressupostos processals, les resolucions judicials, les notificacions, l'auxili judicial, els mitjans d'impugnació, l'execució, les vistes, etc., i que seria complementat per un text reduït per a les especificitats de cadascuna de les altres branques del procés.

L'art. 4 LEC sorgiria, així, amb una clara vocació de servir de "norma model", perquè proclama la supletorietat de manera expressa, de forma que juntament amb els textos processals de cadascuna de les lleis d'aquesta naturalesa s'estableix un text de referència, no només per als casos de llacuna legislativa, sinó com a mecanisme habitual de complementació a falta de regulació específica. És a dir, la seva regulació pretén aglutinar matèries que, segons la seva pròpia Exposició de Motius, tenen un caràcter processal, però que es troben regulades a la Llei Orgànica del Poder Judicial i que n'haurien de ser excloses.

De manera més estricta o limitada, es pot considerar en canvi que la nova LEC no introdueix una novetat, sinó que simplement efectua una compilació d'allò que ja s'havia contingut a les respectives disposicions finals o addicionals de les lleis processals administrativa, laboral, o militar, que s'hi remeten expressament com si es tractés d'un autèntic codi processal, de manera

que la LEC sigui el text processal que ompli les llacunes que plantegen les lleis reguladores del procediment en cadascun dels distints ordres jurisdiccionals.

No obstant això, a hores d'ara la LOPJ conté una regulació processal que no pot ser obviada, perquè segons el principi de jerarquia normativa, de l'art. 9 CE, els preceptes d'una norma amb rang d'orgànica seran aplicables de manera directa respecte d'aquelles altres de rang inferior que regulin la mateixa matèria, la qual cosa és aplicable també a les processals, sense que pugui servir d'excusa el fet que les normes processals no tenen naturalesa orgànica encara que es trobin incloses en una llei amb aquest rang, com ha mantingut part de la doctrina i el debat parlamentari sobre la vigent LEC s'encarregà de desautoritzar.

La LEC, conscient de la vigència de la LOPJ, però amb desig declarat de reforma, recull a la seva Exposició de Motius, apt. V, i per tant sense caràcter normatiu[2], aquesta aspiració de supletorietat, pròpia d'un "codi model", fins i tot coneixent que s'aplicarà la norma orgànica fins que sigui modificada i es remetin els seus preceptes a la llei processal civil. Per la seva banda, quan a la disposició derogatòria única, apt. 3, s'estableix que *"es consideren derogades [...] totes les normes que s'oposin o siguin incompatibles amb el que disposa aquesta Llei"*, cal entendre el que sigui contrari a les normes regulades en la LEC, però no el que es trobi regulat en una norma amb rang superior. I és que l'Exposició de Motius fou redactada per a un projecte que havia de convertir-se en llei amb la consegüent reforma de la LOPJ, però que el joc de les majories parlamentàries va malmetre.

El legislador de 2000 va tenir la intenció de modificar la LOPJ per excloure'n determinats preceptes que considerava de naturalesa simplement processal. No obstant això, el ben cert és que el Parlament exigí la majoria necessària per a la modificació d'una llei orgànica, i en no tenir-la el partit promotor, les reformes no pogueren prosperar. Així, la disposició final dissetena hagué d'habilitar un procediment transitori per al recurs per infracció processal fins que es reformi la LOPJ.

Amb aquesta situació és fàcil concloure que la LOPJ a hores d'ara és una norma d'aplicació directa a tots els ordres jurisdiccionals, i que, malgrat el que es pogués desprendre de l'EM de la LEC, a l'actualitat en cada ordre jurisdiccional s'aplicarà de manera directa la corresponent llei processal que regula el procediment respectiu, i a més a més la LOPJ, mentre que la llei processal civil serà aplicada només amb caràcter supletori, no directe.

Entre els diversos preceptes que han d'aplicar-se de manera directa en els diferents ordres jurisdiccionals, els tres casos més significatius són els que es refereixen a la regulació de l'abstenció i la recusació[3], a la nul·litat d'actuacions[4], i a les propostes de resolució[5].

---

[2] Sobre la falta de valor normatiu de les Exp. de Motius de les lleis, fins el punt de no poder ser objecte directe d'un recurs d'inconstitucionalitat, STC 116/1999, de 17 de juny, que reitera allò ja resolt a les anteriors SSTC 36/1981, 150/1990, 212/1996, i 173/1998.

[3] Els articles 217 a 228 de la LOPJ regulen els procediments d'abstenció i recusació, que seran d'aplicació a tots els ordres jurisdiccionals quan es plantegi alguna d'aquestes qüestions en el transcurs de qualssevol procediments.

Amb independència de tot l'anterior, la integració de les llacunes processals s'haurà de realitzar mitjançant la remissió al dret supletori, en concret, acudint a les disposicions de la LEC, per mitjà de les quals es completa l'heterointegració prevista a les principals lleis d'enjudiciament, on es fa una remissió expressa a la llei processal civil en tot allò que no s'hi ha previst. És el cas de la disposició final primera de la LJCA per al procés administratiu, o de l'addicional primera de la LPL per al procés laboral. Per tant, l'art. 4 LEC apareix com una norma general de tancament que considera aquesta llei dret comú supletori d'acord amb allò que s'ha establert a les altres lleis d'enjudiciament.

D'altra banda, aquest sistema d'integració es completa amb altres remissions particulars a la disciplina de la LEC sobre una determinada matèria o institució en l'articulat de les distintes lleis d'enjudiciament. Per exemple, l'art. 598 de la LECRIM, per als embargaments, o el seu art. 764.2 sobre contingut, pressupostos, i caució substitutòria de les mesures cautelars o de la prestació de caucions; l'art. 984 LECRIM per a l'execució de sentència quant a la responsabilitat civil; i de l'art. 996 LECRIM per a les terceries; l'art. 60.4 LJCA en matèria de prova; l'art. 14 LPL en qüestions de competència; o finalment l'art. 64.9 LORRPM. En puritat, aquests casos de remissió particular a una altra norma sobre una matèria o institució no són supòsits en què se supleixi una llacuna, ja que aquesta realment no existeix, atès que el legislador ha previst la regulació de l'assumpte o qüestió, encara que si bé de forma indirecta per remissió a una altra norma.

En canvi, en els casos en què efectivament existeixi una llacuna sobre alguna qüestió es produirà el moment d'utilitzar les remissions generals a la LEC. La distinció té la seva transcendència pràctica, ja que en els casos de remissió particular no existiran problemes per aplicar les disposicions a què s'ha remès expressament la llei, malgrat possibles diferències en els principis que regeixin en cada ordre jurisdiccional. En canvi, en les remissions generals per a suplir llacunes es poden presentar problemes ateses les peculiaritats de cadascuna de les normes, tant per part de la remitent que presenta la llacuna, com per part de la remesa que conté la solució per a suplir el buit normatiu.

---

Hom pretengué incorporar aquesta regulació a la nova LEC en la literalitat de la LOPJ, però mentre no s'aconsegueixi la reforma tants cops esmentada, la norma a aplicar, no de manera supletòria sinó directa, serà la prevista als esmentats preceptes de la LOPJ.

[4] Arts. 238 a 243 de la LOPJ, en la redacció donada per la Llei 5/1997, de 4 de desembre. Ens trobem davant d'un supòsit que, malgrat els nefastos resultats, car la reforma de 1997 no ha aconseguit de cap de les maneres disminuir el nombre de recursos d'empara, com es volia, continua en vigor a la LOPJ, i l'aplicació del qual també serà directa en tots els ordres jurisdiccionals.

[5] Una vegada més l'EM torna a preconitzar allò que després no es produí, la supressió de les propostes de resolució. L'articulat no regula res sobre aquest tema i l'art. 290 LOPJ continua estant vigent. En efecte, si ens atenem al contingut de l'EM de la LEC, les propostes de resolució haurien quedat derogades. Però no existeix cap precepte a la LEC en què s'estableixi de manera expressa la supressió de les propostes de resolució i, en cas d'existir, resultaria contrari al principi constitucional de jerarquia normativa. Es podrà argumentar que, en no estar expressament regulades, queden suprimides, i així seria si no tinguéssim una norma que és d'aplicació directa, per la qual cosa, s'ha d'entendre que les propostes de providència i d'interlocutòria continuen estant en vigor en tots els ordres jurisdiccionals i, mentre no es modifiqui la LOPJ, hauran de ser utilitzades pels Secretaris judicials per a donar a les interlocutòries l'impuls establert a la llei.

La problemàtica que susciten aquests diversos sistemes és diferent, perquè mentre el primer suposa una remissió molt ampla, la qual cosa permet la interpretació de qui pretén la supletorietat, el darrer ho fa de manera concreta a un precepte determinat, sense que en aquest cas puguin plantejar-se problemes, perquè el legislador de la norma de remissió ha conegut prèviament el contingut del precepte a què es remet i, tot i això, ha decidit no regular la situació concreta en el text de remissió, per aplicar íntegrament el precepte de la norma supletòria.

Tanmateix, l'experiència demostra que això últim no sempre és així, perquè actualment succeeix que la norma supletòria ha estat redactada amb posterioritat a les suplertes, sense que aquestes s'hi hagin adaptat, la qual cosa provoca més problemes que la remissió genèrica a l'empara d'una teòrica impossibilitat d'interpretació.

Els mecanismes d'integració poden ser de dos tipus diferents, d'heterointegració o d'autointegració[6]. En el primer cas, és la supletorietat la que s'encarrega de cobrir les llacunes del text legal; en el cas de l'autointegració, és la tècnica de la interpretació analògica dins del mateix procés l'encarregada de cobrir les absències de regulació específica.

Ambdós mecanismes serveixen per a suplir l'absència de regulació en supòsits concrets, però la LEC en el seu art. 4 s'ha decantat per la fórmula de l'heterointegració. No obstant això, cal examinar amb cautela aquest sistema en el cas de la LECRIM, en una doble vessant; d'una banda, com a principi general tot text legal ha d'ésser autointegrat en cas d'una eventual llacuna, és a dir, s'ha de buscar l'analogia dins dels seus propis preceptes, i dins la seva pròpia branca del Dret, abans d'acudir a qualsevol altra analogia o supletorietat; i, de l'altra, la clàusula de supletorietat que es recull a l'art. 4 de la LEC ha de servir per a suplir els buits legals d'una branca de l'ordenament, però mai de la totalitat, perquè en cas contrari es trencaria aquest caràcter autointegrador de les diferents branques del dret que podria provocar desequilibris difícilment justificables a la llum de la Constitució.

És així que les normes processals després de l'aprovació de la LEC s'integren en un doble sistema: d'una banda, l'art. 4 estableix una remissió genèrica de tots els processos de qualsevol ordre jurisdiccional, inclòs el militar, als preceptes de la LEC com a norma supletòria. Estableix així una clàusula d'heterointegració que culmina les normes d'aquesta naturalesa, ja citades, recollides en els distints textos processals, en què de manera genèrica es contenen normes d'heterointegració. L'art. 4 de la LEC és una clàusula general de tancament que configura aquest text legal com una norma de dret comú supletori i com la culminació o compendi de les altres clàusules de remissió. Però aquesta clàusula d'integració es complementa amb altres d'específiques que es remeten a preceptes o tràmits concrets de la LEC per a dur a terme el desenvolupament d'una fase determinada del procediment.

---

[6] Víctor MORENO CATENA, en F. ESCRIBANO MORA (Coord.), *El proceso civil, Doctrina, Jurisprudencia y Formularios,* vol. I, Ed. Tirant lo Blanch, Tratados, Valencia, 2001.

Aquesta doble remissió suscita dues qüestions. En primer lloc, la remissió genèrica prevista a les diferents disposicions i a l'art. 4 de la LEC pot plantejar alguns problemes sobre l'abast i l'eficàcia de la remissió al dret supletori, i fa possibles nombroses interpretacions analògiques. En canvi, les remissions expresses recullen de manera indubitada la intenció del legislador, per la qual cosa en aquests supòsits no es deixa escletxa a la interpretació analògica, car la llei de remissió ja estableix com vol que s'interpreti la supletorietat en aquests casos concrets.

En puritat, en aquests segons supòsits no es pot parlar de llacunes legals, sinó de supletorietat volguda pel legislador i, per tant, d'estalvi normatiu, perquè no es produeix una llacuna legal no volguda per aquest, sinó una absència intencionada de regulació en considerar aplicable i suficient l'existent a la norma remesa.

Enfront del que pogués semblar, que els majors problemes d'adaptació de normes es presentessin en els casos de supletorietat genèrica, en els supòsits de llacuna legal, i derivats fonamentalment de les genuïnes característiques de cada procés, segons l'ordre jurisdiccional a què pertanyin, a la pràctica és en els casos de remissió concreta on més problemes se susciten, perquè, com ja s'ha dit, en alguns casos les lleis processals suplertes no s'han adaptat a la posterior norma supletòria, de forma que en determinades fases, probatòria en el contenciós-administratiu per exemple, la norma suplerta no es pot adaptar a la supletòria, perquè la primera es refereix a un procés escrit i la segona, la que l'ha de suplir, a un altre de naturalesa eminentment oral, la qual cosa provoca problemes de vegades insalvables.

L'art. 4 no és de fàcil interpretació, perquè *stricto sensu* considera la LEC dret supletori comú de tots els processos judicials ventilats davant de la jurisdicció ordinària i de la militar, la qual cosa planteja diversos dubtes en relació amb el seu abast i amb el mode concret de realitzar la integració de les normes processals.

En primer lloc, respecte de l'abast, resulta estrany que no es consideri els preceptes de la LEC com a dret comú supletori enfront dels procediments constitucionals; i no resulta explicable aquesta omissió, especialment quan la pròpia LOTC, en el seu art. 80, preveu una remissió a la LOPJ i a la LEC en tot allò referit a normes processals, per exemple, per al còmput de terminis, la forma dels actes processals, les comunicacions, etc. Per tant, s'ha d'entendre vigent la remissió de la LOTC, malgrat que la LEC no hagi inclòs els processos constitucionals a l'art. 4.

En el pol oposat es troba la remissió a la jurisdicció militar ja que, malgrat estar inclosa expressament a l'art. 4 de la LEC, la supletorietat resulta en aquest cas pràcticament inoperant, per tractar-se d'una matèria de naturalesa processal fonamentalment penal, i perquè compta amb una disposició específica de remissió supletòria a la Llei d'Enjudiciament Criminal[7].

D'altra banda, existeixen també certs dubtes sobre l'abast material de la remissió continguda a

[7] La disp. addicional primera de la Llei Orgànica 2/1989, de 13 d'abril, Procesal Militar, assenyala que la LECRIM i les seves disposicions complementàries seran aplicables als procediments penals militars, que es regiran per aquestes normes en quant no hi estigui regulat i no s'hi oposi.

l'art. 4, perquè del tenor literal del precepte no es dedueix si comprèn tota mena de normes de la LEC, o si és una remissió exclusiva per a les normes processals, és a dir, per a aquelles que regulen les generalitats del procés i el procediment.

Aquests dubtes queden resolts a favor de considerar la LEC com a dret supletori per a tots els afers de naturalesa estrictament processal, relatius a qüestions generals de qualsevol procés, com: còmput de terminis; règim de la nul·litat dels actes processals; pressupostos processals, capacitat i legitimació de les parts; règim de les resolucions judicials, etc. És a dir, l'art. 4 és l'instrument que permet a la LEC adquirir el paper de norma comuna general en totes aquelles qüestions que per la seva naturalesa siguin comunes a qualsevol procés, aquelles que per la seva íntima connexió amb l'estructura bàsica i essencial de qualsevol procés, puguin ser utilitzades per a suplir una llacuna en un ordre jurisdiccional diferent del civil, sense que interfereixin els principis i característiques pròpies d'aquest ordre jurisdiccional.

Els límits de la supletorietat haurien de quedar tanmateix meridianament clars, perquè no es pot pretendre que l'art. 4 de la LEC serveixi de factor habilitant per a què les normes reguladores de la rebel·lia o de la càrrega de la prova, per esmentar dos exemples concrets, es puguin aplicar davant de possibles llacunes a la LECRIM, perquè el procés penal es regeix per principis diferents, de la mateixa manera que aquesta mateixa remissió no pot servir de forma genèrica per a suplir les possibles llacunes de la LJCA en matèria de terminis d'execució. No obstant això, aquests problemes queden resolts quan es tracta de remissions concretes, al marge d'allò que s'ha previst a l'art. 4 de la LEC, que es recullen en les altres lleis processals i que ja han tingut en compte la naturalesa específica de cada procés i han acudit a aquest sistema de supletorietat per a resultar aplicable, assumint intencionadament les normes del procés civil.

El Tribunal Suprem també s'ha decantat des d'antic per la supletorietat de la LEC a la resta dels ordres[8]. Possiblement a causa que sigui històricament el primer cos processal general, el més complet i el que en origen fou concebut per a servir a la resolució de la majoria de les qüestions litigioses, malgrat que la LECRIM, aprovada un any després, partia amb vocació d'autosuficiència a excepció feta de l'execució de la sentència en els seus aspectes civils. D'aquí que aquesta darrera no compti amb una remissió genèrica, sinó de diferents articles que es remeten a la LEC només per a casos concrets.

Diversos anys després de la seva entrada en vigor, la Llei d'Enjudiciament Civil continua tenint una assignatura pendent, l'aprovació de la reforma de la LOPJ en els seus aspectes considerats processals, i la seva incorporació a aquell text processal, la qual cosa converteix a la pràctica la supletorietat, almenys en part, en una mera declaració d'intencions. Malgrat això, la LEC ha acabat erigint-se en un codi processal comú, integrador de les llacunes que puguin sorgir en l'aplicació normativa en els processos administratiu i social, i en menor mesura, en el penal i el militar.

[8] Vegeu STS, 2a, 26.2.2000, sobre l'art. 921 LEC/1881 i els interessos processals; ATS, 3a, 24.1.2000, o STS, 4a, 1.2.2000.

**Article 5.** *Classes de tutela jurisdiccional.*

1. **Es pot pretendre dels tribunals la condemna a una prestació determinada, la declaració de l'existència de drets i de situacions jurídiques, la constitució, la modificació o l'extinció d'aquestes últimes, l'execució, l'adopció de mesures cautelars i qualsevol altra classe de tutela que prevegi expressament la llei.**

2. **Les pretensions a què es refereix l'apartat anterior s'han de formular davant el tribunal que sigui competent i davant els subjectes als qui hagi d'afectar la decisió pretesa.**

Sembla que la rúbrica de l'art. 5 de la LEC pugui sintetitzar la tutela que els jutges i tribunals poden prestar quan, en realitat, simplement s'ocupa d'enumerar els possibles objectes d'un procés. Es produeix en aquest precepte, per tant, una identificació entre dret d'acció i pretensió exercitada, de manera que el dret d'acció es configura en forma concreta, és a dir, com a pretensió de tutela del dret subjectiu. La conseqüència d'aquesta configuració és la confusió entre dret d'acció i pretensió, la qual cosa determina que només en el cas que la pretensió plantejada sigui de les previstes a l'ordenament pugui garantir-se el dret d'acció del subjecte actuant.

L'art. 5 conté una enumeració no taxativa de les possibles pretensions a exercitar davant d'un tribunal i constitueix una evident novetat en quant recull legalment la divisió de les pretensions que la doctrina i la jurisprudència ja manejaven durant el mandat de la LEC de 1881. Presenta cert interès el fet que es deixa oberta la possibilitat d'altres pretensions, sempre que vinguin reconegudes per una norma legal, perquè permetrà en un futur ampliar el contingut d'eventuals actuacions del jutge a supòsits com el de la tutela preventiva de naturalesa satisfactiva, ja previstos en altres ordenaments (*injunctions* del dret anglès o *rèfèrè* del dret francès), però encara amb difícil encaix en el nostre.

El precepte s'ocupa de les pretensions de cognició, en concret preveu l'existència de pretensions merament declaratives, de condemna i constitutives. Es caracteritzen perquè per, mitjà d'elles, les parts processals sol·licitaran del jutge que, després de conèixer de l'afer en un procés declaratiu, dicti una resolució que posi fi al conflicte entre les parts.

Les pretensions merament declaratives tenen per objecte aconseguir que el jutge dicti un pronunciament en què es declari l'existència o inexistència d'un determinat dret o d'una concreta relació jurídica. En conseqüència, la finalitat perseguida és obtenir certesa enfront de situacions jurídicament discutides o controvertides; d'aquí que el pressupost necessari per al triomf d'aquesta classe de pretensions sigui l'existència d'un *contradictor* que posi en tela de judici la posició jurídica de l'actor, quan es tracti d'una pretensió declarativa positiva, o bé que la condició de *contradictor* l'assumeixi el propi demandant quan la pretensió sigui negativa (per exemple, l'acció negatòria de servitud). La necessitat que el dret o situació jurídica siguin discutits per a un

triomf eventual de la pretensió merament declarativa s'ha vingut exigint per la jurisprudència ja d'antic (STS de 8 novembre de 1994 (Ar. 9317)). En conseqüència, la legitimació per al plantejament de pretensions merament declaratives derivarà del fet de ser titular d'un dret subjectiu o d'una relació jurídica posada en dubte o discutida per algú, o fins i tot del fet d'ostentar un interès legítim per a l'esclariment de la situació jurídica controvertida.

No ha d'existir cap inconvenient, per la seva banda, per admetre pretensions merament declaratives de naturalesa negativa, és a dir, aquelles en què se sol·licita del jutge que declari la inexistència d'un dret o relació jurídica, malgrat que l'art. 5 expressament només reculli la possibilitat de pretensions declaratives de naturalesa positiva ("la declaració de l'existència de drets i de situacions jurídiques").

Amb les pretensions de condemna es busca no només donar certesa a un dret o situació jurídica controvertida, sinó que a més a més se sol·licita del jutge la condemna de la contrapart a realitzar una prestació de donar, fer o no fer. D'aquí que la pretensió de condemna pugui conceptuar-se com a "mixta", perquè conté tant una petició declarativa, adreçada al jutge perquè reconegui l'existència d'un dret controvertit, com, al mateix temps, una petició de condemna al deutor derivada de la seva falta de compliment de l'obligació dimanant del dret declarat.

Una tercera possibilitat que pot revestir l'objecte d'un procés declaratiu són les conegudes com a pretensions constitutives. En elles la part demandant adreça al jutge una sol·licitud per a què realitzi una modificació en la realitat jurídica existent mitjançant la constitució, modificació o extinció d'un dret, situació o relació jurídica. Aquestes pretensions constitutives, per tant, s'adrecen a produir un canvi jurídic en la realitat, creant un dret on abans no existia, modificant una situació jurídica prèvia, o extingint una relació amb existència anterior. La legitimació per al plantejament d'aquestes pretensions es reconeixerà a qui ostenti la qualitat o l'estat jurídic exigit pel dret, relació o situació jurídica la modificació de la qual es pretén (*vgr.*, els cònjuges quan es planteja una pretensió de nul·litat matrimonial).

L'art. 5 també reconeix l'existència de pretensions cautelars, quan permet que les parts puguin sol·licitar de l'òrgan jurisdiccional l'adopció de mesures cautelars. La principal característica de la pretensió cautelar és la seva instrumentalitat, ja que l'adopció de les mesures cautelars s'encaminarà a garantir l'efectivitat d'un procés principal en què es discuteix una pretensió de cognició, o més en concret una pretensió de condemna. Per tant, en definitiva, la mesura cautelar s'adreça a garantir l'efectivitat d'una futura sentència de condemna.

Per últim, l'art. 5 preveu l'existència de pretensions d'execució, en les quals el titular d'un títol de condemna s'adreça al jutge sol·licitant l'execució forçosa de la condemna continguda en algun dels títols d'execució previstos a l'art. 517 d'aquesta LEC.

Aquest article finalitza disposant que les pretensions a formular s'hauran de plantejar davant d'aquells subjectes a què hagi d'afectar la decisió que se sol·licita. Amb això no està fent una altra cosa que reconèixer que l'objecte processal, la pretensió, es connecta íntimament amb el dret

material en joc, fins al punt que tots aquells que es puguin veure afectats hauran de ser emplaçats per a una vàlida constitució de la relació jurídica processal. Per tant, serà la pretensió plantejada pel demandant la que determinarà la relació jurídica controvertida i, com a conseqüència d'aquesta inicial fixació del dret material en joc, quedarà determinada la persona (art. 10 LEC) o persones (art. 12.2 LEC) que hauran d'integrar la part passiva del procés.

La falta d'integració de la part demandada és de summa importància, perquè en aquest cas s'hauria produït una indefensió del subjecte no integrat a la *litis*, malgrat no es vegi afectat per la decisió. Una inadequada integració de la part demandada a l'inici del procés podrà suplir-se mitjançant l'instrument de la intervenció processal (arts. 13 i 14 LEC), o en el tràmit de l'audiència prèvia del judici ordinari (art. 420 LEC).